

1000976-60.2021.8.26.0549

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Alexandre Cesar Ribeiro

Comarca: Santa Rosa de Viterbo

Foro: Foro de Santa Rosa de Viterbo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... da conta para recebimento de valores decorrentes de tráfico de drogas, roubos, extorsões, estelionato etc.). E é óbvio que ninguém abre conta em nome de terceiro para agir de forma lícita.

Ademais, diante da existência da conta impugnada, o autor se viu impedido de utilizar-se de valores decorrentes de seu trabalho, necessários à sua subsistência, poderia ter seu nome vinculado à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rosa de Viterbo

Vara Única

Rua Francisco Carvalho de Andrade, 121, Centro - Santa Rosa de Viterbo-SP

cep 14270-000 - Telefone: (16)3954-1506 - E-mail: santarosa@tjsp.jus.br

Processo Digital nº 1000976-60.2021.8.26.0549 - lauda de

SENTENÇA

Processo Digital nº 1000976-60.2021.8.26.0549

Classe - Assunto: Procedimento Comum Cível - Bancários

Requerente: Paulo Jose Botelho

Requerido: Companhia Global de Soluções e Serviços de Pagamento Sa

Justiça Gratuita

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos moral e material proposta por Paulo Jose Botelho contra Companhia Global de Soluções e Serviços de Pagamento S/A. Alega ser pintor e passou seus dados para que uma contratante efetuasse o pagamento pelos serviços prestados; que esta efetuou a transferência bancária através de PIX, no valor de R\$ 700,00. Como o autor nunca havia habilitado o PIX em sua conta bancária, notou que o importe transferido não foi creditado em sua conta, procurando o autor a contratante. Apurou que havia uma conta aberta por terceiro em nome do autor, junto à empresa ré, e que o valor transferido pela contratante foi creditado na conta em questão. Ao entrar em contato com a instituição ré, tomou conhecimento de que terceira pessoa de prenome José Roberto Romualdo estava movimentando a referida conta bancária. A requerida forneceu uma senha de acesso ao demandante para que somente consultasse os extratos da referida conta; e constatou, ao acessar os extratos, que foram realizadas várias operações bancárias pelo terceiro fraudador. Alega que informou à ré desconhecer tais movimentações e que não a contratou, assinou ou autorizou qualquer abertura de conta junto à empresa demandada. Requereu a devolução do valor de R\$ 700,00, creditado pela contratante na conta bancária aberta ilicitamente, e a ré não respondeu à solicitação.

Pleiteia: a) o encerramento da conta aberta fraudulentamente junto à requerida; b) a condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor de R\$ 700,00, a título de danos materiais; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R\$ 10.000,00. Com a inicial, vieram documentos.

A causa foi recebida com gratuidade judiciária ao autor.

Citada (fls. 29), a ré contestou a demanda de forma intempestiva (fls. 30/58).

Alega nulidade na dispensa da sessão de conciliação, afirmando que tem interesse na realização da referida audiência; aduz perda superveniente do objeto principal da

ação, uma vez que a requerida já autorizou o estorno da operação ao autor e a conta foi cancelada. No mérito, aduz que presta serviços de conta digital semelhante a uma conta corrente de um banco, cujos valores não pertencem à requerida, mas sim à empresas e/ou pessoas físicas cadastradas; que para se tornar cliente, basta baixar o aplicativo "Conta Dotz" e fornecer os dados pessoais e bancários solicitados. Afirma que usa sistema antifraude e que este não identificou atividades suspeitas, pois as operações ora impugnadas foram realizadas mediante apresentação de documentos do autor. Ademais, aduz que não houve comprovação de conduta ilícita culposa por parte da empresa ré e que incabível a inversão do ônus da prova. Argumenta ausência de responsabilidade civil da requerida, pois a situação se deu por culpa exclusiva de terceiros e que a ré também é vítima da fraude. Aduz que incabível a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, pois estes não ficaram caracterizados e pleiteia que, subsidiariamente, na hipótese de fixação de indenização por danos morais, os valores sigam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer o reconhecimento da nulidade da dispensa da audiência de conciliação, o acolhimento da preliminar e, em caso de análise do mérito, a ação seja julgada improcedente. Juntou documentos.

Réplica às fls. 98/103.

Relatados, decido.

Procede-se ao julgamento antecipado da causa, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, pois os fatos estão suficientemente provados por documentos. Reconhece-se a intempestividade da contestação. A ré foi citada em 01/10/2021, o aviso de recebimento da citação foi juntado aos autos em 07/10/2021 (fls. 29), o prazo de contestação se consumou em 04/11/2021; mas a ré apresentou a contestação somente em 10/11/2021.

A despeito da intempestividade da defesa, os efeitos da revelia são meramente relativos, e não impedem que o Juiz aprecie os fatos de acordo com os documentos juntados e com os fatos alegados pelas partes; notadamente porque não existe preclusão em matéria probatória para o Juiz, e deve-se primar pela apuração da verdade real. Por isso, nada impede que a petição de contestação seja mantida nos autos e que o Juízo aprecie os fatos alegados e, especialmente, os documentos juntados pelas partes.

Rejeito a alegação de nulidade pela dispensa da audiência de conciliação, visto que tal ato não configura nulidade. Neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Falta de designação de audiência de tentativa de conciliação que não gera nulidade, pois as partes podem conciliar a qualquer momento" (TJSP, Apelação n. 1017522-48.2016.8.26.0071, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, J. 08/05/2017).

ILEGITIMIDADE DE PARTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. Ré que figura no certificado de registro do veículo na qualidade de proprietária. Preliminar afastada. **PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.** Inocorrência. A simples dispensa da audiência de conciliação não implica em nulidade processual, em vista da ausência de prejuízo para as partes, as quais podem transigir a qualquer tempo. Princípio "pas de nullité sans grief". Ademais, a ré foi alertada na carta da intimação do prazo para apresentação de defesa. Prejudicial rejeitada. **BEM MÓVEL.** Ação de indenização por danos materiais. Aquisição de veículo usado, com posterior apresentação de problemas no motor. Ausência de comprovação de que os defeitos já existiam à época da aquisição do bem. Fatos constitutivos do direito do autor, a quem incumbe o ônus da prova. Dicção do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que não se verifica a existência de relação jurídica de consumo entre as partes, mas sim negócio jurídico decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel realizado entre particulares. Recurso parcialmente provido, para o fim de julgar-se improcedente a lide. Manutenção da penalidade por oposição de embargos de declaração com caráter protelatório. (TJSP, Apelação Cível 1022848-42.2016.8.26.0506, Rel. José Augusto Genofre Martins, 31ª Câmara de Direito Privado, J. 30/09/2019).

Nos presentes autos, o autor expressamente manifestou desinteresse na realização de audiência de conciliação. Ademais, a dispensa do referido ato em nada impedia que as partes, a qualquer momento, transigissem. Apesar de a parte ré, de forma

expressa, ter apontado interesse na sessão de conciliação, o mesmo não se observou do autor que, em réplica, requereu o julgamento antecipado do feito.

Não se verifica qualquer prejuízo às partes a dispensa na realização da audiência de conciliação, principalmente levando-se em consideração que o autor demonstrou total desinteresse na realização do ato.

No tocante à extinção pela perda do objeto, embora a parte ré tenha alegado que efetuou o cancelamento da conta e disponibilizou ao autor o valor creditado pela contratante através de PIX, esta ação também tem pedidos de indenizações material e moral; o que impede extinção do processo sem análise do mérito.

No mérito, a ação é procedente em parte.

A despeito do entendimento da parte ré no sentido de que também foi vítima da fraude, este entendimento não prospera; e isso por sua própria versão acerca de seus procedimentos de segurança.

A ré apresentou documento referente ao regulamento de seus serviços prestados, demonstrando que, para efetuar o cadastro no site ou demais canais, deverá o interessado informar: nome, endereço de e-mail, documento de identificação válido e vigente (CPF, CNPJ ou Documento de Identificação de Estrangeiro), telefone, data de nascimento, gênero e CEP da residência (Fls. 82). Ocorre que os dados exigidos pela ré não oferecem nenhuma segurança quanto a eventuais fraudes, visto que informações como nome, e-mail, documento de identificação, nascimento são facilmente acessados por terceiros fraudadores que destes dados se utilizam para obter vantagens indevidas.

É certo que para as contratações através dos canais digitais, é necessário que sejam realizados procedimentos de segurança outros (não se limitando à exigência de informações pessoais), como forma de minimizar as fraudes comumente perpetradas na internet. A instituição deve se valer de instrumentos de identificação física da pessoa contratante, por meio de comparecimento pessoal em locais cadastrados, identificação biométrica presencial, e assinaturas manuscritas ou digitais.

No caso em questão, a parte ré não apresentou nenhuma comprovação de que tenha realmente sido o autor o contratante da conta impugnada, o que indica que não foi diligente no procedimento de abertura da conta; dando azo à fraude.

Tratando-se de ação indenizatória decorrente de contratação fraudulenta em prejuízo de pessoa natural que não mantinha relação jurídica com a ré, a demanda envolve relação de consumo, pois o autor da ação (vítima) é equiparado a consumidor, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora alega que jamais contratou com a parte ré, que a contratação da conta impugnada decorreu de fraude. O réu, em contestação, reconheceu indícios de que a contratação se deu mediante fraude, tanto que procedeu ao cancelamento da conta de forma administrativa e disponibilizou o levantamento, pelo autor, do valor creditado indevidamente na conta pela contratante do demandante.

Acolhe-se o pedido declaratório e a consequente ordem de cancelamento da conta indevidamente registrada em nome da parte autora junto à ré.

A parte autora alega a inexistência de relação jurídica, pois sustenta que nunca requereu a contratação de conta junto à requerida, bem como que nunca manteve qualquer relação contratual com esta.

Tratando-se de alegação de fato negativo (inexistência de débito) pelo autor, ônus da se inverte, pois o fato negativo não se prova. Assim, incumbia à parte ré provar a efetiva contratação e a regularidade da conta de titularidade do autor.

Em tema de ônus da prova, não se pode exigir daquele que alega fato negativo a prova direta desse fato (pois essa prova seria diabólica). Quando a parte alega a inexistência do fato, cabe à parte contrária (que alega o fato positivo) a prova da existência da relação jurídica impugnada (a prova do fato positivo).

Conforme clássica lição:

“Assim como a observação exterior nos deu o princípio supremo para o ônus da prova, o princípio ontológico; assim também a observação interior nos dá outro princípio subordinado ao primeiro, e a que eu chamarei lógico; um princípio que tem origem nos meios de prova que o homem possui para induzir a certeza em outro homem: denominamos este princípio lógico, porquanto a sua origem imediata encontra-se nos meios de convicção que o espírito humano possui, se bem que a sua origem mediata e

primordial se encontre também, naturalmente, no modo de ser das coisas. Eis o princípio que chamamos lógico: na colisão entre um facto positivo e um facto negativo, quem afirma o facto positivo tem de o provar, com preferência a quem afirma o facto negativo. É o velho brocardo: probatio incumbit ei qui dicit, non quinegat." (MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. 2. ed. Lisboa: Livraria Clássica, 1927, p. 133).

Contudo, no caso, a parte ré nada comprovou para demonstrar a regularidade na inscrição da conta, inclusive reconhecendo os indícios de fraude.

A própria parte ré admite, na contestação, que não contratou com o autor e que houve fraude cometida por terceiro; o que torna incontroversos os fatos.

Assim, é de rigor o acolhimento do pedido declaratório, para reconhecimento da inexistência da relação jurídica e consequente encerramento da conta, sem qualquer ônus ao autor.

Como consequência do reconhecimento da irregularidade da criação da conta em nome do autor, importa à ré efetuar a devolução do valor que seria destinado ao demandante, mas foi depositado na conta fraudulenta.

Não se tratando de cobrança indevida, a devolução, no valor de R\$ 700,00, deverá ser realizada pela ré ao autor de forma simples, com atualização monetária e juros legais da mora contados desde a data do depósito deste valor na conta fraudulentamente aberta em nome do autor.

Por fim, no que tange ao pedido indenizatório por dano moral, este é procedente em parte.

Houve, no caso, ato ilícito em detrimento do autor da ação, para o qual a ré concorreu por manifesta negligência.

A parte ré, pura e simplesmente, aceitou contratação fraudulenta, e, com isso, viabilizou que dados do autor da ação fossem fraudulentamente utilizados por terceiro (estelionatário), com toda a sorte de riscos e exposição do autor a danos (uso da conta para recebimento de valores decorrentes de tráfico de drogas, roubos, extorsões, estelionato etc.). E é óbvio que ninguém abre conta em nome de terceiro para agir de forma lícita.

Ademais, diante da existência da conta impugnada, o autor se viu impedido de utilizar-se de valores decorrentes de seu trabalho, necessários à sua subsistência, poderia ter seu nome vinculado à prática de crimes que desconhecesse a existência, e poderia até ser alvo de investigações policiais relacionadas a lavagem de dinheiro e outros crimes; de modo que a parte ré causou intenso sofrimento psicológico, angústia e sentimento de impotência em face da grave injustiça provocada por ato arbitrário da empresa ré.

A requerida foi extremamente negligente ao não verificar a correção de seus procedimentos de segurança e de identificação dos clientes; especialmente por viabilizar o cadastro de conta em nome do demandante, por terceiro fraudador. Acrescente que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prescreve claramente que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Os serviços bancários (e qualquer outro serviço prestado na economia) devem ser seguros (arts. 6º, I, e 14, § 1º, ambos do Código do Consumidor), e um o mais grave vício de segurança que pode haver na prestação de um serviço é o de erro na identificação do contratante (consumidor).

Consoante lição de Sérgio Cavalieri Filho, "o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum". (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª ed., 3ª tir., Malheiros Editores, 2000, p. 80).

O dano é in re ipsa, pois decorre da própria gravidade decorrente da injustiça do fato. Além disso, posturas como as da parte ré fomentam fraudes, possibilitam a atuação de quadrilhas que forjam documentos e obtêm dinheiro em prejuízos de

peças probas; violando toda a segurança de um sistema econômico e jurídico (do sistema bancário).

Diante disso, cotejados estes pontos, ante o baixo prejuízo financeiro do autor (R\$ 700,00), o tempo em que o autor foi privado de valores que lhe pertenciam, os riscos decorrentes do uso fraudulento dos dados do autor em conta bancária aberta de forma fraudulenta, a gravidade da negligência cometida pela parte ré, as condições econômicas das partes envolvidas no ilícito moral, a necessidade de punição da parte ré (em razão da função educativa e preventiva da indenização moral), mas considerando que a ré, durante do trâmite desta ação, reconheceu a falha e cancelou a conta; fixo a indenização em R\$ 5.000,00; monetariamente atualizada da data desta sentença, mais juros legais da mora contados da data do ilícito (data da abertura da conta bancária).

Ante o exposto, reconheço a intempestividade da contestação, rejeito a matéria preliminar e julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta por Paulo José Botelho (CPF 325.837.598-41) contra Companhia Global de Soluções e Serviços de Pagamentos S/A (CNPJ 32.024.691/001-50), para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que a ré encerre a conta bancária aberta com os dados do autor junto à parte ré, bem como cancele todo e qualquer débito em face do autor da ação em decorrência dessa conta bancária; ficando a parte ré proibida de cobrar qualquer valor do autor em razão do uso dessa conta bancária, e devendo a ré comunicar aos órgãos de controle de segurança bancária a ocorrência da abertura da conta de forma fraudulenta; fixado o prazo de cinco dias úteis para cumprimento dessas obrigações, sob pena de multa diária de R\$ 200,00 (limitada a trinta diárias de multa) para o caso de descumprimento;

b) condenar a ré a restituir ao autor da ação, mediante depósito judicial nestes autos, o valor de R\$ 700,00, monetariamente corrigido e acrescido dos juros legais da mora de 1% ao mês contados da data do depósito em conta (21/07/2021); e

c) condenar a ré a pagar, uma indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00, monetariamente corrigidos da data da sentença, mais juros legais da mora (1% ao mês) contados da data da abertura da conta (15/04/2021).

Sucumbente na quase-totalidade da causa, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo, e ao pagamento de honorários ao(à) advogado(a) da parte autora, no valor de R\$ 1.000,00 (monetariamente corrigidos da data desta sentença).

Determino à serventia que comunique ao Serasa e ao SCPC (se possível, por meio digital), que os dados do autor da ação estão sendo utilizados fraudulentamente para abertura e movimentação de contas bancárias por terceiros; devendo essa informação constar para que haja rigoroso controle da identidade em contratos envolvendo os dados do autor da ação (devendo a Polícia ser acionada caso haja suspeita de uso indevido de dados do autor da ação).

Oportunamente, manifeste-se a parte autora em termos de cumprimento de sentença.

P. I. C.

Santa Rosa de Viterbo, 27 de janeiro de 2022.

Alexandre Cesar Ribeiro
Juiz de Direito
(assinatura digital)